



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

Paraná, 26 de julio de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel E. ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA 5493/2014/1/CA1, caratulado: "LEGAJO DE APELACIÓN DE DI - MED S.R.L.; DE TORRES, FIDEL NICOLÁS; HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN EN AUTOS ´DI - MED S.R.L.; DE TORRES, FIDEL NICOLÁS; HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN POR INFRACCIÓN LEY 24.769´", proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fidel Nicolás De Torres y María del Carmen Hernández a fs. 19/33, contra la resolución obrante a fs. 1/18, en cuanto decreta el procesamiento de los nombrados, por considerarlos coautores del delito de simulación dolosa de pago de la empresa DI-MED S.R.L., previsto en el art. 11 de la ley 24.769 y en función del art. 45 del CP, todo ello de conformidad a los arts. 306 y 308 del CPPN; y en cuanto dispone el embargo de los nombrados hasta cubrir la suma de CINCUENTA MIL PESOS (\$50.000). El recurso es concedido a fs. 34.



En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 46 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, el Dr. Osvaldo Miguel García Girard, defensor de los coimputados Fidel Nicolás De Torres y María Del Carmen Hernández, y la Dra. Diana Marina Núñez, en representación de la querellante AFIP-DGI, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. García Girard sostiene que la acción ya estaba prescripta al momento de la denuncia. Alude al monto previsto en el art. 1 de la ley penal tributaria e indica que debe tomarse por cada uno de ellos y en forma separada. Destaca que, en tal caso, ninguno excede dicho monto por lo que debe revocarse el procesamiento.

Analiza el delito de simulación dolosa de pago. Alude al procedimiento que establece la AFIP, por el cual se establece una serie de requisitos que, en el caso, no se realizaron. Sostiene que la compensación no existió, por lo que el delito no se concretó y alude a la presentación de la multinota, donde se dejó sin efecto el pedido de compensación.

Indica que a sus defendidos les es aplicable el art. 16 de la ley 24.769 ya que se regularizó





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

espontáneamente su situación. Reitera la ausencia de responsabilidad penal y alude al testimonio del inspector de la AFIP. Evoca que nada impidió a que la AFIP expidiera la boleta de deuda y menciona la pericia contable.

Respecto de Hernández, menciona que integraba la sociedad pero que en su indagatoria demostró que no tuvo intervención en los hechos, por lo que no hay motivo para que sea procesada. Solicita se revoque el auto de procesamiento de sus defendidos.

b) Por su parte, el Sr. Fiscal General analiza la figura penal prevista en el art. 11 de la ley 24.769. Menciona el umbral expresado por el art. 1 de dicha norma y su correlación con aquella figura. Destaca que el legislador en el delito de simulación dolosa de pago no aludió al monto como lo hace en la evasión.

Refiere al hecho que se les atribuye a los imputados y destaca que, con retenciones que eran falsas, se pretendieron compensar tributos. Cita lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa "Szczzech" y efectúa consideraciones respecto de la compensación como medio extintivo de las obligaciones.

Concluye que el hecho ocurrió y que tanto De Torres como Hernández, tenían acceso al dominio de las cuentas de la empresa. Propicia se confirme la resolución.

Fecha de firma: 26/07/2017

Alta en sistema: 27/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29796558#184199066#20170726102327104

c) A su turno la Dra. Núñez reseña los hechos que se investigan y alude a la compensación como medio de pago.

Analiza la figura penal que se les imputa y menciona que el procedimiento aludido por la defensa para realizar la compensación fue derogado en el año 2004. Refiere al formulario de compensación y a los requerimientos que se hizo a la empresa, los cuales no fueron contestados, y la posterior declaración jurada rectificativa.

Cita el fallo de la CFCP en la causa "Szczecz" y concluye que la compensación existió. Considera absurdo sostener que la Multinota puede dejar sin efecto algo que supuestamente no existió y considera que el reproche penal continua incólume.

Efectúa consideraciones respecto de los plazos a tener en cuenta respecto de la prescripción y concluye que no ha transcurrido el plazo máximo de 6 años. Evoca que Hernández era socia y administradora de la clave fiscal. Solicita se confirme el auto de procesamiento.

d) Oportunamente, las partes ejercieron su derecho de réplica.

II- Que, debe tenerse presente que las actuaciones principales se originan a raíz de la denuncia formulada el 28/07/2014 por personal de la AFIP-DGI por conductas detectadas en oportunidad de efectuar una





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

investigación al contribuyente DI-MED S.R.L., las que constituirían prima facie la figura prevista en el art. 11 de la Ley Penal Tributaria, esto es, la simulación dolosa de pago.

Instruidas las actuaciones, luego de incorporarse una serie medidas probatorias -pericias, testimoniales e informes, entre otros-, el 29/03/2016 fueron indagados María del Carmen Hernández y Fidel Nicolás de Torres, oportunidad en la que se les imputó *"Que, entre los meses de agosto de 2009 y marzo de 2011, simuló dolosamente el pago de la suma de pesos seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho con dieciocho centavos (\$648.458,18), mediante la utilización de retenciones ficticias sufridas conforme los certificados de retenciones presentados en las declaraciones juradas de IVA por los períodos correspondientes a agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2009; abril, mayo y junio de 2010 y marzo de 2011, de la firma DI MED SRL, con domicilio fiscal en calle Villaguay N° 1040 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, CUIT N° 33700140119, generando saldos de libre disponibilidad por igual monto que fueron utilizados para simular el pago de otras obligaciones fiscales que adeudaba."*

El 23/03/2017 el a-quo procesó a María del Carmen Hernández y Fidel Nicolás de Torres como coautores



del delito de simulación dolosa de pago, decisión contra la cual se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, en primer lugar corresponde señalar que si bien la defensa ha realizado manifestaciones sobre la posible prescripción de la acción penal en estos actuados, cierto es que no se cuenta en esta instancia con todos los elementos necesarios para dar un correcto tratamiento de la cuestión, encontrándose el Tribunal imposibilitado a dichos efectos, por lo que -en su caso- deberá ser abordado en la instancia a-quo.

Sentado aquello, cabe poner de resalto que lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa "SCZCZECH" (FPA 12012962/2012/3/CFC1, del 22/12/2015, Registro N° 2411/15.4) impone la necesidad de un nuevo análisis de la cuestión que generara el voto mayoritario de esta Cámara en el Fallo del 27/09/2013 en dichas actuaciones, en las cuales se investiga -al igual que en las presentes- la posible comisión del delito de simulación dolosa de pago.

Sin perjuicio del criterio allí sostenido, el análisis realizado por el Tribunal nomofiláctico equipara los conceptos de "pago" y "compensación" escudriñando al efecto las previsiones del Capítulo IV "Del pago" de la Ley 11.683 (t.o. Dcto 821/98) que en su art. 23 refiere al pago propiamente dicho y en su art. 28 a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

compensación, concluyendo que, uno y otro son medios aptos de cancelación de obligaciones tributarias, incluidos en un concepto amplio de pago propio del derecho tributario. A partir de ello sostuvo la Sala IV de la CFCP que "... el pago referido en el art. 11 de la Ley 24769, denota los supuestos de extinción de las obligaciones tributarias previstos en los art. 23 y 28 de la Ley 11.683. ..." (del voto del Dr. Borinsky).

Más allá de nuestra anterior interpretación, no encuentro nuevos elementos que me permitan enervar tal conclusión, motivo por el cual interpreto que la compensación, en tanto medio de cancelación de las obligaciones incluida en el Capítulo IV "Del pago", constituye pago y su utilización a los fines extintivos puede extinguir una obligación pero, cuando tal compensación se funde en créditos inexistentes, también es apta para tipificar la conducta del art. 11 de la Ley 24769.

b) Ingresando al caso que nos ocupa y superada esta primera cuestión, debo manifestar que lo que se encuentra en discusión es si la conducta desplegada por los imputados califica en los términos del art. 11 supra referido. No se encuentra controvertida ni la existencia del crédito a favor del Fisco, ni tampoco el ejercicio de la pretensión compensatoria de dicho crédito. Toda la controversia finca en la aptitud de la conducta



desplegada por los imputados en orden a simular el pago de la obligación reconocida.

Así, la defensa postula que la existencia de una rectificatoria y la ausencia de un acto administrativo que otorgue fuerza cancelatoria a la pretendida compensación, obsta a la configuración de la conducta típica. Sin embargo, la "simulación" se perfecciona en el momento mismo en que el agente intenta el engaño y con prescindencia de que lo consiga. No requiere de aceptación del Fisco, sino de la intención ardidosa o engañosa destinada a provocar el eventual perjuicio fiscal. Las conductas posteriores podrán eventualmente considerarse en orden a la tentativa, el desistimiento u otra circunstancia pero de manera alguna elimina la conducta de origen que sigue siendo la simulación dolosa de pago.

En efecto, en el caso de autos, se encuentra acreditado que se utilizaron certificados de retención falsos en las declaraciones juradas de IVA de la firma DI MED SRL, por los períodos correspondientes a agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2009; abril, mayo y junio de 2010 y marzo de 2011, para generar saldos de libre disponibilidad y, de tal modo, simular dolosamente -a través de compensaciones- el pago de las obligaciones fiscales que registraba dicha empresa. Así surge del cúmulo de probanzas agregadas en estas actuaciones,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

especialmente de la documentación acompañada por el Fisco, del testimonio de Luis María Olivari (fs. 116/118) y de la pericia contable (fs. 138/148 vta.), todo lo cual fuera puesto de resalto por el magistrado en la resolución recurrida.

Por otro lado, respecto de la participación de los imputados en el hecho endilgado, cabe destacar que el a-quo ha puesto de resalto que Fidel Nicolás De Torres revestía, a la época del suceso, el carácter de socio gerente de la empresa DI MED S.R.L., tal como surge de la documentación remitida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (cfr. fs. 18/53), reuniendo las cualidades funcionales que prevé el art. 14 de la ley 24.769, y que junto a María del Carmen Hernández, eran las personas habilitadas ante la AFIP-DGI para administrar la clave fiscal de dicha sociedad.

Respecto de la situación de la Sra. Hernández, el uso de la Clave Fiscal es de carácter personal y, con prescindencia de que la misma hubiere delegado su utilización en terceros -Contador, persona de confianza, etc.-, desde el punto de vista tributario y penal, la responsabilidad por tal uso está en cabeza de la titular de la misma.

En efecto, todas las circunstancias referidas ut-supra, permiten concordar con el criterio del Sr. Juez a-quo, por lo que propongo al Acuerdo rechazar el recurso

Fecha de firma: 26/07/2017

Alta en sistema: 27/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29796558#184199066#20170726102327104

de apelación interpuesto por la defensa de Fidel Nicolás De Torres y María del Carmen Hernández y, en consecuencia, confirmar el procesamiento de los nombrados como coautores del delito de simulación dolosa de pago de la empresa DI-MED S.R.L. -art. 11 de la ley 24.769-.

En este estado, debe recordarse que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; que el auto de procesamiento no causa estado, y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

IV- Finalmente, atento a que en la audiencia oral la defensa no sostuvo el agravio respecto del embargo decretado en autos, corresponde tenerlo por desistido, de conformidad con lo dispuesto por el art. 454 -tercer párrafo- del C.P.P.N.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: Que he de compartir la solución propuesta por el Dr. Alonso, sin perjuicio de efectuar algunas consideraciones.

Que el presente caso guarda similitud con cuanto fuera traído a resolver a esta Alzada en los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

autos: "SZCZECH..." (FPA 12012962/2012/2/CA1, del 27/09/2013).

En dicha ocasión deje sentado en mi voto disidente, en relación al tipo previsto por la Ley 24769 en su art. 11, que *"...se trata de una verdadera figura de peligro, que pretende proteger anticipadamente a los bienes jurídicos tutelados, criminalizando aquellos hechos que puedan ponerlos en riesgo... se intenta reprimir la simulación del pago de obligaciones tributarias o previsionales, que si bien pueden constituir actos preparatorios de otro tipo de delitos, inducen a error al fisco sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias o previsionales"* (cfr. Edwards, Carlos E., "Régimen Penal Tributario. Leyes 24.765 y 24.769"; 4° ed. actualizada y ampliada, Ed. Astrea, 2000, pág. 65).

Que, por otra parte señalé en cuanto a los medios comisivos, que la enunciación legal es meramente ejemplificativa, ya que comprende no sólo la falsificación de registraciones o comprobantes, sino también "cualquier otro ardid o engaño" (cfr. Haddad, Jorge, "Ley Penal Tributaria Comentada", 5° ed., Ed. Lexis Nexis, 2005, pág.86).

Que asimismo sostuve que por las características exigidas para la acreditación del pago de las obligaciones que la norma menciona, la maniobra



ardidosa o engañosa necesariamente deberá implicar algún documento o instrumento.

En relación a ello, surge la cuestión acerca de qué es lo que debe simularse, coincidiendo los autores en 'el pago total o parcial de las obligaciones mencionadas en la norma'.

Que en el presente caso, se habrían 'simulado' retenciones en el IVA que nunca se efectuaron, mediante la declaración y presentación por la firma DIMED SRL ante el Fisco de 'certificados de retención' falsos, que no se corresponden con la realidad económica constatada por el ente fiscal.

Que siguiendo esta línea, las aparentes retenciones sufridas por DIMED SRL constituyen 'lo simulado' -aspecto requerido por el tipo objetivo de la figura- y mediante ellas se produjo la generación de crédito fiscal a su favor en el IVA, independientemente de que dicho saldo positivo -originado ilícitamente- haya sido ulteriormente utilizado para compensar o cancelar deudas fiscales anteriores.

En este sentido, cabe señalar sobre el punto que *"...lo habitual es que el pago se realice después del acaecimiento del hecho imponible... sin embargo, hay diversas figuras en las que el pago se hace antes de que dicha obligación nazca. Esto sucede por ejemplo en los anticipos tributarios, pagos a cuenta exigibles en otros*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5493/2014/1/CA1

tributos y en los importes retenidos o percibidos"
(cfrse. Villegas, Héctor B., Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 8ª edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, pág. 377)

Ello es conteste con la correcta hermenéutica que deriva del art. 27 de la ley 11683, según el cual las retenciones son pagos a cuenta de la suma final de los tributos por las que fueron practicadas.

Que por todo lo expuesto, lo dicho en torno a la configuración de la maniobra ilícita e intervención de los imputados en aquella, satisface -con el grado de convicción requerido para esta instancia procesal- cuanto exige la figura endilgada por el magistrado.

En consecuencia, adhiero al rechazo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Fidel Nicolas De Torres y María del Carmen Hernández y la confirmación del auto venido en recurso, así como al desistimiento dictado respecto del embargo.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta por el Dr. Daniel Edgardo Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fidel Nicolás De Torres y María del Carmen Hernández y, en consecuencia, confirmar la



resolución de fs. 1/18, que decreta el procesamiento de los nombrados como coautores del delito de simulación dolosa de pago de la empresa DI-MED S.R.L., de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

II- Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Fidel Nicolás De Torres y María del Carmen Hernández, contra el punto II) de la resolución de fs. 1/18 y, en consecuencia, confirmar el embargo decretado sobre los bienes libres de los nombrados -art. 454 tercer párrafo, del C.P.P.N.-

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ
CON SU VOTO

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET
JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

